

Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC

Resolución 17413-034 de 2013

FUNDAMENTO PARA PROFERIR FALLO ABSOLUTORIO - Ausencia de ilicitud sustancial y eximente de carácter legal.

El disciplinado presuntamente incurrió en una conducta a título de dolo por haber ejercido su profesión de abogado, en proceso ejecutivo estando impedido para ello.

El disciplinado fue absuelto toda vez que la conducta reprochada no se ajusta a los parámetros descriptivos del Código Único Disciplinario para concluir que, efectivamente, incurrió en infracción disciplinaria alguna, en el entendido que el cuestionado ejercicio de la profesión lo hizo dentro del marco de la excepción previsto en el estatuto de la profesión de la abogacía, esto es, en causa propia.

FUENTE FORMAL – Ley 734 de 2002. Artículos 4, 5 y 48 Numeral 1. Comisión de un delito. Código Penal Ley 599 de 2000 Artículo 421. Asesoramiento y otras actuaciones ilegales.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. Por desempeñar funciones ajenas a su cargo sin estar capacitado para atender lo encargado.

“...Al confrontar los hechos que motivaron esta actuación disciplinaria, con las excepciones previstas en el artículo 29 de la Ley 1123 de 2007 para el ejercicio de la profesión de la abogacía por parte de quienes ostentan la calidad de servidores públicos, es válido concluir que el disciplinado XXXX actuó a la luz de la excepción referida, y no en el marco de una conducta ni disciplinaria ni penalmente relevante.”

FUENTE FORMAL – LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 4, 5 y Estatuto del abogado, art. 29

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número de proceso:	1704-01-2012-176
Número y fecha del fallo:	17413-034, del 30 de septiembre de 2013
Asunto:	Fallo de Primera Instancia
Criterio de Selección:	Fallo absolutorio

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Se procede a proferir fallo de primera instancia dentro del expediente administrativo disciplinario No. 1704-01-20012-01, seguido en contra de (XXXX).

CARGO FORMULADO

Cumplidas las etapas de rigor y habiéndose dado traslado para alegatos de conclusión, mediante auto del pasado 21 de mayo del año en curso, la Subdirección Técnica de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC, en ejercicio de las facultades legales conferidas por la Ley 734 de 2002, los Decretos 4173 de 2011 y 0985 de 2012, procede a proferir fallo de primera instancia dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2012-176.

Cargo

"(...) Conforme a la decisión por medio de la cual se calificó el mérito de las pruebas, de fecha 24 de junio del año 2013, el señor XXXX, en su condición de Gestor III Nivel 303 Grado 03 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, adscrito a la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, presuntamente incurrió objetivamente en una conducta descrita en la ley como delito sancionable a título de dolo, por cuanto se consideró que pudo haber ilegalmente ejerció su profesión de abogado, al obrar como apoderado judicial de XXX, en proceso ejecutivo de mínima cuantía a cargo del Juzgado 26 Civil Municipal de la ciudad de Medellín, actuación donde se libró mandamiento de pago el 25 de junio del año 2010 y el disciplinado asumió la representación judicial a partir del 17 de enero del año 2011.

La conducta del disciplinado se enmarcó dentro de la descripción de falta gravísima del numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, esto es, la realización objetiva de una conducta descrita en la ley como delito sancionable a título de dolo, cometida con ocasión a su cargo dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, asociada a la infracción penal del artículo 421 del Código Punitivo. (...)"

CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

CASO CONCRETO

Los artículos 128 y 142 de la ley 734 de 2002, aplicables a este contexto procesal por virtud a lo ordenado en el artículo 223 de la normatividad, determinan los requisitos probatorios fundamentales que debe contener todo fallo disciplinario de carácter sancionatorio. Dichas normas obligan al fallador a sustentar su decisión final en pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso, las cuales deben conducir inequívocamente a la demostración de la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-176

La certeza corresponde a un estado mental de seguridad y, por lo tanto, de firme adhesión o asentimiento a la verdad de una proposición, fundada en una razón que excluye completamente y, por ende, libera del temor de la verdad de lo contrario. Certeza del hecho es la segura, firme, precisa y clara convicción que el operador disciplinario tiene acerca de la ocurrencia de una falta disciplinaria. Certeza de la responsabilidad es el convencimiento que adquiere el operador disciplinario acerca de la comisión de una conducta por parte del destinatario de la ley disciplinaria, resultante del análisis crítico y juicioso de las pruebas obrantes en la investigación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se analizará el material probatorio obrante en el expediente, conjuntamente con los argumentos expuestos en las diligencias de versión libre y espontánea y escrito de descargos, para concluir si el disciplinado es o no responsable de la comisión de la falta disciplinaria prevista en el numeral 10 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, conforme a la imputación elevada en el auto de pliego de cargos.

De la certeza sobre la ocurrencia de la falta

Por auto de fecha 9 de septiembre del año 2011, el Juzgado 26 Civil Municipal de la ciudad de Medellín, dispuso compulsar copias ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para que se investigara disciplinariamente al servidor público de esa entidad XXXX, por cuanto pese a estarse tramitando un proceso ejecutivo de mínima cuantía, donde los demandados actuaron en causa propia, tanto XXX como XXX otorgaron poder al codemandado XXXX, para que los representara en la acción por ostentar la calidad de abogado, mandato que ejerció en contravía de la restricción prevista en el artículo 29 de la Ley 1123 del año 2007 en criterio del administrador de justicia.

Por razón de los anteriores hechos, el pasado 24 de junio del año que avanza se formuló auto de pliego de cargos en contra del disciplinado XXXX, como posible autor de la infracción disciplinaria gravísima prevista en el numeral 10 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que al tenor literal dice:

"Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón; con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo."

La imputación disciplinaria se complementó con la conducta delictiva del artículo 421 del Código Penal, cuyo contenido es el siguiente:

"Artículo 421. Asesoramiento y otras actuaciones ilegales. El servidor público que ilegalmente represente, litigue, gestione o asesore en asunto judicial, administrativo o policivo, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.

Si el responsable fuere servidor público de la rama judicial o del Ministerio Público i a pena será de prisión de uno (1) a tres (3) años, e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años."

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-176

En criterio de esta Subdirección, el otorgamiento de los mandatos al disciplinado, su presentación ante el despacho a cargo de la acción ejecutiva incoada contra el mismo y el ejercicio de las facultades en diligencia de interrogatorio de parte cumplida el 11 de enero del año 2011, determinaron la realización objetiva de la conducta delictiva de asesoramiento y otras actuaciones ilegales, en el entendido que se presentó un ejercicio ilegal de la acción de litigar.

Pues bien, llegada esta instancia y atendiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar como se presentaron los hechos, y a la luz de los pronunciamientos de constitucionalidad en torno a la restricción del ejercicio de la profesión de la abogacía por parte de los profesionales vinculados a las entidades públicas, es necesario efectuar un nuevo análisis para concluir si los hechos presentados realmente configuraron la infracción disciplinaria enrostrada en el auto de pliego de cargos.

Al Juzgado 26 Civil Municipal de la ciudad de Medellín se asignó el conocimiento de la demanda instaurada por la señora XXX, en contra de XXX y XXXX, último servidor público en servicio en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, con ocasión al no pago de obligación contraída con la firma CYPRES - Casas y Prefabricados, respaldado con letra de cambio y pagaré en blanco a favor de la vendedora.

Por tratarse de proceso ejecutivo de mínima cuantía, los demandados XXX y XXXX contestaron la demanda actuando en causa propia¹⁹, para más adelante los primeros otorgar poder al disciplinado XXXX para atender los asuntos relacionados con la acción ejecutiva, mandatos que pese a ser otorgados en el mes de octubre del año 2010, solo fueron presentados el 17 de enero del año 2011, cuando se surtió el interrogatorio de parte de la señora XXX, actividad solicitada por el disciplinado dentro de su contestación de la demanda.

Tiempo después, más concretamente el 9 de septiembre del año 2011, el despacho de conocimiento dispuso compulsar ante las autoridades disciplinarias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, para que se investigará una posible conducta disciplinariamente relevante por parte del disciplinado, al actuar como apoderado de los codemandados XXX, en contravía de lo previsto en el artículo 29 de la Ley 1123 del año 2007, por la cual se estableció el régimen disciplinario de los abogados y restringió el ejercicio de la profesión por parte de quienes ostentaban la condición de servidores públicos.

Con relación a la incompatibilidad para el ejercicio de la profesión por parte de quienes tienen la condición de servidores públicos, a la luz del artículo 123 de la Constitución Política, la Corte Constitucional estudió la exequibilidad del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, y encontró razonable limitar la potestad del desempeño profesional del derecho a quienes se encontraban vinculados con el Estado, porque de alguna manera podrían verse favorecidos por el conocimiento de situaciones particulares o llegar a afectar el cumplimiento de los fines e intereses de la misma administración por la falta de dedicación al cumplimiento de las funciones propias de sus cargos.

Al respecto señaló la Corte:

La disposición prohíbe el ejercicio de la profesión de abogado a los empleados públicos y trabajadores oficiales, aun en uso de licencia, con lo cual, como bien lo señalan el interviniente y el Procurador (E) se protegen simultáneamente varios intereses y principios constitucionales. De un lado, se busca transparencia en el ejercicio profesional, pues el ordinal acusado evita que un servidor público utilice los poderes derivados de su cargo en su ejercicio profesional, con lo cual se controlan ciertos riesgos sociales ligados a la profesión de abogado (CP art. 26) y además, se logra una mayor igualdad entre los litigantes y los justiciables, ya que se impide que la función pública se traduzca en tratos discriminatorios entre las personas (CP art. 13). De otro lado, el artículo protege la función pública, pues garantiza su moralidad, imparcialidad y eficacia (CP art. 209) ya que asegura que el empleado oficial se dedique esencialmente al cumplimiento de los deberes de su cargo, en la medida en que impide que la satisfacción de intereses particulares por parte del funcionario obstaculice el cumplimiento de las labores de interés general que le han sido encomendadas. (Sentencia C-1004 de 2007)

Esta postura de la Corte fue reiterada más adelante, al estudiar precisamente la constitucionalidad del artículo 29 de la Ley 1123 de 2009,

"En este orden de ideas, la incompatibilidad entre el ejercicio de la abogacía y el servicio público pretende la realización de fines constitucionalmente legítimos, entre los cuales se destacan: (i) evitar que la persona aproveche, en detrimento del interés general, las atribuciones derivadas de su cargo como servidor público en su desempeño como abogado con intereses privados, sean éstos onerosos o gratuitos; (ii) controlar los riesgos que supone una práctica profesional concomitante entre la actividad pública y privada, donde el interés general puede entrar en tensión con expectativas individuales; (iii) propender por una mayor igualdad entre los abogados, impidiendo que la función pública se traduzca en tratos discriminatorios originados de la vinculación con el Estado; (iv) asegurar la dedicación exclusiva a la función pública y la consecuente realización de los principios de moralidad, imparcialidad y eficacia que la caracterizan."

Lo anterior resulta absolutamente lógico, si se tiene en cuenta que la vinculación con el Estado impone el aseguramiento de intereses superiores, como la igualdad, la convivencia pacífica, un orden justo, entre otros, frente a intereses particulares de quien ostenta la profesión de abogado y decide voluntariamente asumir un rol dentro de la administración pública, como el desarrollo profesional y personal.

Aun así, el legislador y la propia Corte Constitucional reconocieron límites en la aplicación de esta restricción, bajo el entendido que en algunos eventos el servicio público no se ve afectado si sus agentes ejercen la profesión de la abogacía, constituyéndose en una excepción a la prohibición, y es el caso del litigio en causa propia y los abogados de pobres, prerrogativa reconocida incluso desde la expedición del Decreto 196 de 1971, que reglamento el ejercicio de la profesión de abogado antes de la promulgación de la ley 1123 de 2007.

En el Decreto 196 de 1971, se indicó por parte del legislador:

"Artículo 39. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:

*1º Los empleados públicos y los trabajadores oficiales, aún en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo o cuando el respectivo cargo se los permita. Pero en ningún caso los abogados a contrato podrán litigar contra la Nación, el Departamento o el Municipio, según la esfera administrativa a que pertenezca la entidad o el establecimiento al cual presten sus servicios, **excepto en causa propia** o los abogados de pobres en las actuaciones que deban adelantar en ejercicio de sus funciones."*(Negrillas fuera del texto).

Y en La ley 1123 de 2007, se reglamentó así:

"ARTÍCULO 29. Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:

*1. Los servidores públicos, aun en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo o cuando el respectivo contrato se los permita. Pero en ningún caso los abogados contratados o vinculados podrán litigar contra la Nación, el departamento, el distrito o el municipio, según la esfera administrativa a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios, **excepto en causa propia** y los abogados de pobres en las actuaciones que deban adelantar en ejercicio de sus funciones."*(Negrillas fuera del texto).

Las razones para permitir el ejercicio de la profesión en causa propia están íntimamente ligadas al ejercicio de un derecho igual de carácter constitucional, como es el derecho de defensa, pues nadie más idóneo que el propio profesional para representar sus intereses en un asunto que lo afecta en su órbita personal, ya sea de carácter penal, laboral, fiscal, disciplinario o incluso, civil.

Al confrontar los hechos que motivaron esta actuación disciplinaria, con las excepciones previstas en el artículo 29 de la Ley 1123 de 2007 para el ejercicio de la profesión de la abogacía por parte de quienes ostentan la calidad de servidores públicos, es válido concluir que el disciplinado XXXX actuó a la luz de la excepción referida, y no en el marco de una conducta ni disciplinaria ni penalmente relevante.

Ello es así, porque como se advierte dentro de lo actuación disciplinaria, el proceso promovido en el Juzgado 26 Civil Municipal de Medellín fue promovido en su contra, situación que lo autorizaba para ejercer su profesión de abogado, y se trataba de una acción de menor cuantía, aspecto que tampoco demandaba la designación de un abogado para representar a los demandados.

En segundo lugar, la diligencia llevada a cabo el 17 de enero del año 2011, interrogatorio de parte de la demandante, se cumplió por solicitud que al respecto elevara el disciplinado al momento de dar contestación a la acción impetrada en su contra, precisamente en ejercicio del derecho de postulación en causa propia previsto en el artículo 29 de la Ley 1123 de 2007.

Aunque para ese momento se presentaron los mandatos otorgados por los codemandados en la acción civil promovida que involucró al disciplinado, su ejercicio se limitó exclusivamente a su presentación, bajo el entendido que no hubo actuación anterior o posterior que demandara su ejercicio efectivo, porque como se indicó la prueba fue pedida por el disciplinado en ejercicio de su derecho a representarse y no en nombre de los demás sujetos procesales accionados.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-176

Conforme a lo anterior, es nítido entonces que la conducta reprochada al disciplinado XXXX no se ajusta a los parámetros descriptivos del código disciplinario único para concluir que, efectivamente, incurrió en infracción disciplinaria alguna, en el entendido que el cuestionado ejercicio de la profesión lo hizo dentro del marco de la excepción previsto en el estatuto de la profesión de la abogacía, esto es, en causa propia, por lo que deberá ser absuelto del cargo formulado en decisión precedente.

En todo caso, no está demás advertir al disciplinado para que situaciones como la ocurrida con los codemandados no se repita en ningún escenario, pues aunque el desinterés de una parte pueda afectar la solución pronta de un litigio, lo correcto sería buscar la designación de un apoderado que los represente y no asumir su representación por la simple razón de ostentar la condición de abogado.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO: ABSOLVER al señor XXXX, en su condición de servidor público de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, del cargo imputado como autor de la falta disciplinaria gravísima del numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, acorde con las razones expuestas.

SEGUNDO: Contra la presente decisión procede el recurso de apelación, el cual podrá interponerse en los términos de los artículos 110, 111, 112, 115 y 119 del Código Disciplinario Único.

TERCERO: Notificar la presente decisión en los términos de los artículos 100, 101, 103, y 107 de la Ley 734 de 2002. Para el efecto se comisiona a la Directora Seccional de Aduanas de Medellín. Por la Secretaría se librarán las comunicaciones de rigor.

CUARTO: En firma la presente decisión, registrarla ante la Procuraduría General de la Nación y comunicarla a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para su ejecución.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ADRIANO MORENO PONCE

Subdirector Investigaciones Disciplinarias -ITRC

Director del Proceso